

1500284-91.2021.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA FRANCIELE GOES QUERUBIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

JÉSSICA FRANCIELE GOES QUERUBIM foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 21/06/2021, transportou e trouxe consigo, para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500284-91.2021.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500284-91.2021.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA FRANCIELE GOES QUERUBIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

JÉSSICA FRANCIELE GOES QUERUBIM foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 21/06/2021, transportou e trouxe consigo, para fins

de consumo de terceiros, 11,60 gramas de cocaína sob forma de pó (quinze porções), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 134/136).

Notificada, apresentou resposta às fls. 175/177, reservando-se ao direito de defesa após a instrução processual.

A denúncia foi recebida às fls. 178/189, em 26/11/2021.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 213/214). Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, em memoriais (fls. 215/219), expôs que não há como ter certeza que a droga pertencia à acusada, impondo-se a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da benesse do art. 33, §4º, da legislação de regência. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Vagner de Oliveira Preto relatou que na data dos fatos, o Conselho Tutelar procurou a Polícia Civil; acompanhavam acusada em decorrência de denúncia de maus-tratos à filha; foram até o endereço da residência, não estava na casa; localizaram filha em uma vizinha; conseguiram entrar em contato com a ré, estava em rodoviária de Monte Sião, acredita que para entrevista de emprego; voltaram até a casa, fizeram revista; localizaram quinze porções de cocaína; tinham denúncias de que estava namorando menor de idade, João Vitor (vulgo Barroso); tinham informações de que estavam atuando em conjunto no tráfico de drogas; autorizou entrada na residência; não lembra se ela estava junto quando da prisão do namorado; informações recebidas do Conselho Tutelar; João Vitor “bastante envolvido”; entrada na casa: não recorda muito bem, parece que teve de entrar pela janela; sabe que alguma coisa teve que pular a janela, pois não estava abrindo pela frente; aparelho celular foi apreendido; não recorda se explorado conteúdo do celular. Cassiano França de Lima expôs que foram acionados pelo Conselho Tutelar para averiguar denúncias de maus-tratos; tinha conhecimento de que envolvida com traficância; em conversa com vizinhança, souberam que criança estava na casa de uma das vizinhas; entraram em contato via telefone, atendeu, disse que estava em rodoviária em Monte Sião; franqueou entrada em residência; encontradas quinze porções de cocaína; chegou a quebrar o vidro da porta com murro; disse que podia ser do namorado, mas que não era dela; namorado: menor apreendido na sexta-feira anterior aos fatos; criança estava com uma criança de idade, cinco casas à frente; ela deu a volta, pulou pela janela e abriu porta de dentro para fora; não chegaram a pular a janela. Otávio Franca Moraes, conselheiro tutelar à época, narrou que Jéssica negligenciava Manuele; na época tinham decidido por afastar a criança e entregá-la para a tia; marcaram consulta com médico e ela não levou a criança; depois disso houve indícios de que traficava; informação chegou ao Conselho Tutelar; foram até a residência para proceder à retirada da criança; não estavam; na hora que estavam saindo do local, senhora saiu, e disse que criança estava com ela; fizeram afastamento e entregaram para a tia; posteriormente, souberam que havia sido encontrada; estava presente até o momento em que a criança foi encontrada; notificaram Jéssica para prestar esclarecimentos; foi muito evasiva; a partir daí começaram a pensar em afastar a criança; foi comunicada em várias ocasiões; criança alimentada a base de leite, um pouco subnutrida; conhecia namorado dela por nome; sempre souberam que envolvido com tráfico; não acompanhou quando foram buscar Jéssica na rodoviária nem apreensão das drogas; desnutrição foi constatada anteriormente.

A acusada nega as imputações. Afirmou que estava procurando trabalho em Monte Sião/MG; ligaram, perguntaram onde estava; perguntaram sobre localização da filha;

disse que estava na tia "de consideração"; falaram que era para ficar esperando; fizeram um monte de perguntas; chegando perto de casa; entraram na rua; pararam, pediram para abrir a porta da casa para verem se tinha alguma coisa; disse que chave estava na bolsa da filha, na tia Dalva; voltou e falou que chave não estava lá; janela do fundo estava aberta; pulou com Vagner e Tony; abriu, Cassiano entrou e já saiu; Tony pediu celular, passou senha começou a procurar; Vagner entrou, procurou coisas; no celular viu conversa com primo, na qual falava que estava "cheirando"; droga não era sua; encontrada junto das roupas; contudo, no dia anterior havia limpado o local; não presenciou localização das drogas; estava com Tony na cozinha; não tem antecedentes; chegou a ir no Conselho/fórum; não vê a filha desde que foi presa; recebeu carta da mãe; depois de seis meses tia levou para a mãe; nunca teve relacionamento com o adolescente João Vitor; é vizinho; morava perto da casa; não deu depoimento na delegacia; não sabe porque foi escrito; quando João Vitor foi preso, foi até a delegacia porque a mãe dele estava com COVID; foi para saber o que iriam fazer com ele; droga surgiu da mão dos policiais; falou brincando com o primo que estava cheirando; só bebe e fuma cigarro; pagava aluguel na casa - R\$300; desempregada fazia duas semanas; estava trabalhando no Café Marrocos; pediu para sair porque ficou com medo por conta das denúncias de maus-tratos; não sabe porque policias fariam isso; mulher de "Barroso" (João Vítor) é Flávia; quando trabalhava no Café Marrocos, filha ficava com a vizinha; pai estava preso, não ajudava; quando deu depoimento na delegacia, acha que assinou o papel, mas não leu, estava muito nervosa; na delegacia só insistiram em perguntar de quem era droga; disse que não era sua; delegado disse que além de tráfico assinnaria maus-tratos.

Com efeito, há inúmeras inconsistências na busca domiciliar, a desaguar na anulação das provas daí decorrentes. Pela análise dos depoimentos, com relação à apreensão das drogas, incontroverso que ocorrida sem qualquer indício prévio de que o local era destinado ao seu depósito, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas pela acusação, que não foram ao local para apurar o crime de tráfico, mas para resgatar a filha da acusada, em virtude das acusações de maus-tratos.

A manifestação do Conselho Tutelar, juntada às fls. 68/70, denota os indícios de maus-tratos relacionados à infante, que constitui fundamento suficiente à efetivação do resgate. Todavia, não há qualquer indício da prática de tráfico de drogas por parte da acusada.

A partir das suspeitas de traficância relatadas pelas testemunhas, caberia à Autoridade Policial instaurar o pertinente inquérito policial, posto que o art. 5º, I, do CPP, determina, para os crimes de ação pública incondicionada, a abertura de ofício.

Segundo a doutrina especializada: "por força do princípio da obrigatoriedade, que também se estende à fase investigatória, caso a autoridade tome conhecimento do fato delituoso a partir de suas atividades rotineiras (v.g., notícia veiculada na imprensa, registro de ocorrência, etc.), deve instaurar o inquérito policial de ofício, ou seja, independentemente de provocação de qualquer pessoa (CPP, art. 5º, I). Nesse caso, a peça inaugural do inquérito policial será a portaria, que deve ser subscrita pelo Delegado de Polícia e conter o objeto da investigação, as circunstâncias já conhecidas quanto ao fato delituoso, assim como as diligências iniciais a serem cumpridas" (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 4ª ed., p. 129) - grifou-se.

Na hipótese, além de não ter sido instaurado o inquérito policial para confirmar/infirmar os indícios prévios, os agentes públicos compareceram ao local para a realização de diligências relacionadas ao resgate da criança, o que macula o ingresso domiciliar posterior, ante o inequívoco constrangimento ilegal em desfavor da ré.

A uma, porque sequer estava em casa, mas em rodoviária na cidade de Monte Sião/MG. Os agentes foram até a acusada, trouxeram-na para sua residência, e pediram para que abrisse a porta e franqueasse a entrada da guarnição. Ainda que tenha afirmado que consentiu com o procedimento, inequívoco o constrangimento ilegal, já que não havia quaisquer indícios registrados de que o local era destinado ao depósito de drogas.

Nesta toada, de acordo com o art. 240, §1º, do CPP: "Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: h) colher qualquer elemento de convicção"; imprescindível, contudo, a expedição de mandado, conforme disposição expressa do art. 241 do CPP: "Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado".

A fundada suspeita não pode ser pautada em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo-se a presença de elementos concretos que indiquem a necessidade da expedição do mandado.

No caso, além de sequer ter sido solicitada a expedição de mandado judicial, não há quaisquer parâmetros objetivos justificadores do ingresso domiciliar, certo que o encontro posterior de drogas não pode justificá-lo.

De acordo com o C. STJ (AgRg no HC 681782/RO): "O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito" – grifou-se.

O fato de os agentes terem ido até cidade localizada em outro Estado – ainda que limítrofe –, obrigado a acusada a entrar na viatura – sem qualquer acusação e/ou indício justificador do cerceio temporário da liberdade –, e "pedido" para que abrisse a porta, inclusive tendo de pular a janela para fazê-lo, demonstram, inequivocamente, o constrangimento ilegal, ainda que tenha informado em Juízo que a entrada fora franqueada, já que também manifestou seu nervosismo quando em contato com a Autoridade Policial, que em tese teria dito que "além de tráfico assinaria maus-tratos".

Em reforço, no HC 598.051/SP, a Corte Superior atestou que:

A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige (...). O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" (...). O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (...). A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação – amiúde irreversível – de todo o processo, em prejuízo da sociedade (...). Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos – diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à

inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local (...). Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial – meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada – legitimar a entrada em residência ou local de abrigo – grifou-se.

Por último, em regime de repercussão geral, a Suprema Corte, no RE n. 603.616, fixou o seguinte entendimento: "Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico (...). A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida" – grifou-se.

No caso, a documentação das fls. 42/88 foi recebida pela promotoria em 15/09/2020 (fl. 42). A prisão ocorreu cerca de 09 (nove) meses depois. Ainda que as notícias da traficância tenham sido recebidas posteriormente, em meados de junho de 2021, não há fundamento para a não instauração de inquérito policial visando à apuração do delito. Cria-se uma situação contraditória: de um lado, há a urgência na devassa domiciliar, sem mandado e sem quaisquer indícios prévios, inclusive com a busca da acusada em outra cidade para franquear tal entrada. De outro, há o retardo imotivado na apuração preliminar dos inícios relacionados às denúncias pretéritas, inclusive para justificar a expedição de mandado de busca domiciliar.

A conclusão é a imprestabilidade da prova para fins processuais, ante a flagrante violação ao devido processo legal.

Em reforço, de pontuar-se outras contradições na atuação policial: A) todos os documentos produzidos na fase administrativa dão conta da presença de dois agentes: Vagner e Cassiano. Do depoimento da acusada, por sua vez, denota-se a presença de um terceiro agente, "Tony", o qual, inclusive, teria pulado pela janela para ingressar no domicílio e verificado as mensagens do celular da acusada; B) os agentes informaram que não acessaram o celular da ré quando da ocorrência, o que vai de encontro ao seu depoimento, que mencionou com detalhes o evento, inclusive com fornecimento de senha pessoal; C) quando do encontro das drogas, a acusada não acompanhava a diligência, pois estava em cômodo distinto, junto de Tony, que visualizava as mensagens do celular.

Tais constatações reforçam a imperiosa necessidade de invalidação da prova, já que o acompanhamento da diligência constitui direito daquele que tem o domicílio devassado, especialmente no caso concreto, em que sequer havia ordem judicial para fazê-lo.

Desta forma, em razão da inequívoca arbitrariedade decorrente da indevida entrada em domicílio, em contrariedade ao art. 5º, XI, da CF, a absolvição é medida de rigor.

Posto isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para absolver a ré JÉSSICA FRANCIELE GOES QUERUBIM, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as

guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006) e restitua-se o celular apreendido à acusada (fl. 10).
Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA